

1500208-55.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 40 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o réu e o adolescente traziam consigo e tinham em depósito as porções da referida droga no local acima indicado, notório por ser ponto de narcotráfico, onde realizavam a respectiva venda ilegal.

Desta forma, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500208-55.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500208-55.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY MENEZES COSTALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

WESLLEY MENEZES COSTALES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, II, "j", do Código Penal porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 19 de fevereiro de 2022, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia Covid-19, por volta das 21 horas, na Rua Newman, 100, Caetetuba, nesta cidade e Comarca de Atibaia, envolvendo em sua prática o adolescente I. T. DE. O., com o qual agia em concurso de agentes, com unidade de desígnios, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito, 40 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o réu e o adolescente traziam consigo e tinham em depósito as porções da referida droga no local acima indicado, notório por ser ponto de narcotráfico, onde realizavam a respectiva venda ilegal.

Desta forma, ao perceberem a presença de policiais que patrulhavam a região, demonstraram nervosismo e foram abordados. Em revista pessoal, com o réu foram encontradas 15 porções de entorpecente bem como a quantia de R\$ 31,25, ao passo que com o adolescente outras 15 porções da droga.

Na ocasião, o adolescente infrator ainda revelou que havia mais droga escondida

dentro de um cano, próximo, que pertencia a ambos. Então, os milicianos foram averiguar e ali acharam o restante dos entorpecentes. Ademais, ainda quando da abordagem, tanto o réu como o inimputável confessaram a traficância, admitindo a posse de todas as porções encontradas, bem como que realizavam a venda em concurso da droga. Na delegacia, porém, o réu negou a prática delitiva, imputado ao adolescente a responsabilidade pelas drogas. Este, por sua vez, tratou de tentar isentar o réu, admitindo parcialmente a posse dos entorpecentes e que realizava a traficância. Em auto de constatação preliminar, verificou-se que as substâncias apreendidas são entorpecentes constantes da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. Ainda segundo consta, é certo que o crime em análise foi praticado durante a noite e na vigência de estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6/20.

Às fls. 79/81 foi concedida liberdade provisória ao réu, mediante a aplicação de medidas cautelares.

O réu foi notificado (fls. 130), e apresentou defesa prévia (fls. 139/140), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 141/144).

O réu foi citado (fls. 161).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 165/166).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 170/173).

A defesa requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, argumentando, em síntese, que não há provas de que WESLLEY estava traficando (fls. 176/177).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 02), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16), nas fotografias (fls. 17/19), no laudo toxicológico (fls. 116/118), e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, disse que quando do acontecido, encontrava-se em uma adega, oportunidade em que lá apareceu seu amigo I.; em dado momento, deixou o local e foi atrás do cachorro, que havia fugido; neste momento, apareceram os policiais no local, tendo sido revistado; nada de ilícito foi encontrado consigo; na ocasião, os policiais encontraram algumas pedras de crack com I.; consigo foi encontrada apenas uma pequena quantia de dinheiro, que, na verdade, pertencia a I.; não é traficante, e nenhuma droga foi encontrada em seu poder; jamais respondeu a processo criminal (fls. 08).

Em juízo, interrogado, negou os fatos. Questionado por que acha que está sendo acusado, disse que não sabe responder; questionado por que os policiais diriam que estava com uma pochete com drogas, e que confessou a traficância, se isso não fosse verdade, disse que não sabe o motivo, mas não estava com nada, sendo que tudo pertencia ao menor, que assumiu; na ocasião, ficou nervoso, com medo, e não soube conversar e se explicar, pois tem déficit de atenção; já tinha tomado um copo de Whisky, então ficou nervoso; o menor, que falou para não responder os policiais, disse que as drogas eram suas, mas negou depois; questionado se estava junto com o adolescente, que disse que a droga era sua, e ficou quieto, disse que não; o menor, que já o conhecia da escola, falou para se acalmar, e disse que, ao chegar na Delegacia, deveria ligar para sua família; não sabia que podia ligar, pois nunca tinha passado por isso; na Delegacia, ligou para sua família e conseguiu se acalmar; ficou muito nervoso, e não conseguiu explicar nada; questionado se está sendo falsamente acusado pelos policiais, que estão incriminando um inocente, disse que sim; trabalha como ajudante de pedreiro, e tem renda mensal de R\$ 1.500,00; estudou até o segundo colegial; não foi processado anteriormente; questionado o que

estava fazendo no ponto de tráfico, disse que estava tomando um copo, mas não estava no ponto, e sim próximo, em uma adega, ao lado; quando estava saindo da adega, os policiais chegaram; não conhecia os policiais, por isso ficou nervoso; questionado por que ficou nervoso, se não conhecia os policiais e não estava fazendo nada de errado, disse que toma remédio, ficou nervoso com a situação, e achou que ia acabar ali, sendo que o adolescente assumiu; está nervoso, e não está conseguindo explicar direito; às reperguntas da defesa, disse que antes da abordagem, o adolescente deixou dinheiro consigo, na pochete, sendo que não tinha nenhuma droga; estava com a pochete, então o adolescente saiu do lugar em que estava; ia saindo da adega, quando a polícia chegou, e o menor voltou correndo, com o cachorro na mão, e assumiu tudo aos policiais; na ocasião, ficou nervoso, por ser maior de idade; questionado pelo juízo onde estava a droga, disse que estava com o adolescente, sendo que, naquele momento, não sabia, e tomou conhecimento na Delegacia, sendo que o menor falou, na viatura, que a droga estava com ele, e em um cano, próximo ao local; questionado pela defesa de quem era o cachorro, disse que era de I.; questionado pelo juízo se I. estava traficando ou brincando com o cachorro, disse que ele estava vendendo drogas, mas o cachorro escapou da casa dele; até então, não sabia que o adolescente estava traficando, sendo que ele explicou isso dentro da viatura, quando foram conduzidos à Delegacia; na ocasião, I. disse que estava realmente vendendo drogas; quando o cachorro escapou, I. foi buscar o animal e, quando estava voltando, a polícia chegou; foi abordado primeiro, e I., em seguida, foi trazido para perto (fls. 165/166).

A testemunha Filipi Barbosa Bucciarelli, policial militar, ouvida às fls. 165/166, disse que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Caetetuba, no Santa Clara, local conhecido nos meios policiais pelo intenso comércio de drogas; ao adentrar a via, visualizou WESLLEY e I. que, ao notarem a presença ostensiva da polícia, demonstraram nervosismo, tentando sair do lugar onde se encontravam, mas não lograram êxito em fugir, tendo sido abordados; em revista pessoal, foram encontradas, com WESLLEY, 15 pedras de crack, além de cerca de R\$ 31,00; indagado sobre o que estava fazendo no local com I., WESLLEY disse que estava vendendo os entorpecentes, que admitiu serem dele; diante dos fatos, solicitou apoio e conduziu o réu à Delegacia; questionado se já conhecia o réu e o menor de outras abordagens, disse que conhecia WESLLEY; questionado se a droga estava junto ao corpo do réu, disse que estava na pochete, na cintura dele, juntamente com o dinheiro trocado; às reperguntas da acusação, questionado o que foi encontrado com I., disse que foi encontrada a mesma quantidade de droga, 15 pedras de crack, sendo que, posteriormente, o menor informou à equipe onde havia mais algumas pedras de crack escondidas em local próximo; questionado o que foi encontrado nesse local, disse que pedras de crack iguais às que estavam com ele.

A testemunha Patrick da Silva Xavier, policial militar, ouvida às fls. 165/166, disse que realizava patrulhamento pelo bairro Santa Clara, local conhecido pelo diuturno comércio de drogas, mais especificamente uma viela, onde é comercializado, exclusivamente, crack; ao adentrar a via, visualizou o réu e o menor, em local conhecido como ponto do tráfico, sendo que, ao notar a presença da equipe, ambos demonstraram certo descontrole emocional, tentando sair do local, então foi realizada a abordagem, ocasião em que foram localizadas, com WESLLEY, 15 pedras de crack, em uma pochete que estava na cintura dele, além de R\$ 31,00, em notas trocadas; com I., foram localizadas outras 15 pedras de crack, tendo o menor informado que, em um cano, próximo ao solo, havia mais 10 pedras de crack, idênticas às que eles traziam consigo; diante dos fatos, foi solicitado apoio, sendo o réu e o menor conduzidos ao plantão policial; questionado se já conhecia algum deles de outras abordagens, disse que já havia abordado ambos no mesmo local, porém nada de ilícito havia sido encontrado anteriormente; questionado se os dois confirmaram que estavam traficando, disse que ambos confessaram a traficância; questionado se a droga que foi encontrada com WESLLEY estava junto a ele, disse que sim, as drogas estavam acondicionadas em uma pochete, junto ao corpo do réu.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, interrogado em solo policial e em juízo, negou os fatos, alegando, em síntese, que as drogas pertenciam a I., e que está sendo falsamente incriminado

pelos policiais. Disse, também, que antes da abordagem, o adolescente entregou a pochete que, no entanto, continha apenas dinheiro. No entanto, sua negativa foi infirmada pelas demais provas produzidas, restando claro o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos fatos criminosos. Senão, vejamos.

Os policiais, cujos relatos se mostraram firmes e consistentes, narraram que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto do tráfico de drogas, quando visualizaram o réu e o adolescente, que demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da equipe, razão pela qual foi realizada a abordagem. Disseram, também, que foram encontradas, com WESLLEY, 15 pedras de crack, em uma pochete em sua cintura, além de R\$ 31,00, em notas trocadas, sendo que, com I., foram encontradas outras 15 porções da mesma droga, tendo o menor informado que havia outras drogas em um local próximo, onde foram achadas mais 10 porções de crack. Disseram, ainda, que o réu e o adolescente admitiram a traficância quando foram abordados, sendo que já conheciam o réu de outras abordagens.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não tinham, mesmo, interesse maior na gratuita acusação do réu.

Portanto, não é minimamente crível a versão do réu de que está sendo falsamente incriminado, já que não trouxe aos autos nada que sequer levantasse alguma dúvida quanto à veracidade dos relatos firmemente prestados pelos policiais, relatos que vieram corroborados pelas demais provadas trazidas aos autos, inclusive pelo laudo pericial supracitado, bem como pelas fotografias juntadas.

Aliás, de se observar que, conforme narraram os policiais, as drogas encontradas com WESLLEY estavam acondicionadas em uma pochete, em sua cintura, pochete que o réu confirmou que levava consigo, embora tenha alegado que continha apenas dinheiro, pertencente ao adolescente. Ademais, interrogado em juízo, WESLLEY sequer soube explicar por que estava em posse da pochete, o que demonstra a fragilidade da

sua narrativa.

Assim, ao contrário do que alegou a defesa, em seus memoriais, verifica-se que o robusto conjunto probatório trazido aos autos é plenamente capaz de ensejar a condenação do réu, uma vez que os relatos dos policiais se mostraram firmes e coerentes, tendo sido narrado como se deu a abordagem, ocasião em que foram encontradas, com o réu, em uma pochete, e com o adolescente envolvido na prática criminosa, bem como em local próximo, 40 porções de crack, embaladas individualmente, prontas para a venda, além de R\$ 31,00, em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada, estando claro que o réu estava, de fato, na traficância, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes (fls. 67).

Culpabilidade normal à espécie. Não há informações sobre sua conduta social ou personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas. Quanto à natureza e quantidade do produto, nada a considerar.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Quanto ao valor da diária, deverá ser fixado acima do mínimo, já que o réu noticiou, em seu interrogatório, que tem renda mensal de R\$ 1.500,00. Assim, levando-se em conta que o valor da diária deve corresponder a 1/30 avos dos rendimentos do réu, o valor deve ser fixado em R\$ 50,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal, posto que o crime foi praticado durante estado de calamidade, decretado em março de 2020, em razão da pandemia covid-19 (art. 385, do CPP), bem como a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 08).

Assim, compenso a agravante do estado de calamidade com a atenuante da menoridade relativa, neutralizando seus efeitos, mantendo a pena no patamar fixado.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, conforme já observado, fez-se presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, uma vez que a prática delitiva envolveu adolescente. A pena é aumentada em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Não obstante seja tecnicamente primário, o réu foi surpreendido em posse de elevada quantidade de entorpecentes, quantia que não seria confiada a alguém que não tivesse profundo envolvimento com o ilícito, além de R\$ 31,00, em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada, estando evidente que se dedicava às atividades criminosas.

Ademais, traficando crack, o réu fazia parte de uma cadeia de criminosos envolvidos desde a produção do entorpecente até sua aquisição pelo usuário. Dedicou-se, portanto, à prática de atividade criminosa consistente em traficância, não fazendo jus ao benefício do parágrafo 4º.

Neste sentido: "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(...) 7. Não há que se falar no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois está provado que o réu se dedica a atividades criminosas, haja vista terem sido encontradas em seu poder 34

pedras de "crack", sendo o encarregado, justamente, da disseminação, propriamente dita, das substâncias entorpecentes, que de mais a mais não consta fossem por ele produzidas. Por sinal, para a produção do "crack", reclama-se toda uma estrutura técnica, laboratório químico, posse de substâncias químicas, que também não consta fossem mantidos pelo réu, de modo que, necessariamente, como acima adiantado, está ele inserido na ponta final de uma corrente criminosa. Precedentes do STF. (...)" (TJ-SP - APL: 00496557320118260577 SP 0049655-73.2011.8.26.0577, Relator: Aírton Vieira, Data de Julgamento: 15/09/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/09/2014).

Por fim, não se pode ignorar o grande dano que vem sendo causado pelos supostos 'pequenos traficantes'.

A ilusão de que eles são figuras socialmente inofensivas, não pode cegar o entendimento do julgador, a quem a lei deu a faculdade de aplicar o benefício do parágrafo 4º, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação. E não se justifica o argumento de que o crime é praticado sem violência ou grave ameaça, e de que o réu é primário e de bons antecedentes.

Primeiramente, o fato de o réu ter sido PEGO pela primeira vez, não quer dizer que ele esteja PRATICANDO o fato criminoso pela primeira vez.

Outrossim, por trás de todo 'pequeno traficante', há os grandes fornecedores. A função do intitulado 'pequeno traficante' é primordial na cadeia criminosa, sendo que o fracionamento do tráfico vem sendo usado como artifício dos traficantes em geral, inclusive, como forma de terem suas condutas desclassificadas para uso próprio, diante da pequena quantidade encontrada em seu poder, fazendo com que muitos julgadores absolvam os grandes responsáveis pela entrega das drogas aos viciados: 'o traficante de porta de escola', o 'pequeno traficante', o 'traficante-viciado'.

No entanto, a conduta deles deve ser analisada com o devido rigor.

Conforme brilhante explanação de EDILSON MOUGENOT BONFIM, Doutor em Direito Processual Penal, Professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e Escritor: "Costuma-se dizer que grande parte dos presidiários hoje - e se justifica o aumento da população carcerária também por isso -, que grande parte dos presidiários, advém do 'pequeno tráfico de drogas' e que nós deveríamos ter uma política criminal voltada ao encarceramento 'do grande traficante' - tenho visto isto com a certa recorrência de declarações de autoridades na mídia. Não sei como se faz essa distinção de 'pequeno traficante' para 'grande traficante', ao ponto do 'grande' merecer a prisão e o 'pequeno' não. Um 'grande traficante' não vai ele próprio traficar, levar 10 toneladas de cocaína ao local. Ele se vale dos 'pequenos' para a distribuição. Todo soldado que entra neste exército quer ser General, e se o Estado premiar, no primeiro dos seus delitos, de tráfico, ainda que 'pequeno', será como que um prêmio, um incentivo, para que ele busque o 'generalato', afinal de contas, o Estado estará lhe passando a mão na cabeça, como recomendam, uns tantos quantos gênios do Direito, que não conseguiram baixar, com as suas ideias, a criminalidade em local nenhum do mundo. Foi preciso que um homem quebrasse o paradigma mundial, destes que especulavam com discursos penais, e diziam que nós deveríamos tratar com blandícia aquele que cometer o 'pequeno crime', que nós deveríamos tratar com comiseração o 'pequeno delinquente'. Nós tínhamos, então, uma matriz piedosa, que dizia que o Estado não tinha legitimidade de punir aquele que cometesse um 'pequeno delito'. Um homem quebrou esse paradigma, não farei um elogio vazio (...), farei um elogio pautado naquilo que é história. Nova Iorque, antes e depois de Rodolfo Juliani. Antes, tomada por gangues, onde havia criminalidade imperando em todos os quadrantes sociais e a política de Tolerância Zero, que até um Presidente Francês, socialista, mandou seus estudiosos para trazer a 'tolérance zéro' para França, modelo que foi discutido mundialmente com este homem, que quebrou o paradigma e disse: 'Tolerância Zero desde o primeiro delito, porque nós assim temos verdadeira piedade do Homem', nós impediremos que ele componha uma 'sinfonia criminosa musical' no futuro, porque já no primeiro delito, na primeira 'nota musical criminosa', nós o puniremos, e aí ele saberá que existe o Estado para punir aquilo que, muitas vezes, faltou autoridade paterna, faltou autoridade escolar, faltou alguma autoridade que é preciso chegar o Estado

com a sua voz, com a sua força, com os seus regramentos, para fazer alguma verdade imperar. Então, o equívoco que se recita é se tratar 'pequeno criminoso', 'pequeno traficante' e 'grande traficante', e só o segundo estaria sujeito à prisão. Ora, o 'pequeno' ele anda de acordo com as suas 'pernas financeiras'. Ele não é grande, não é porque ele tem escrúpulos, é porque ele não pode. Ele trafica 100 gramas porque ele não pode traficar 10 toneladas. Se ele pudesse, ele o faria. O dolo é o mesmo. Ontologicamente, o ser criminoso e a danosidade social que isto provoca ou impacta, é a mesma. O 'grande traficante' se vale da sua rede de 'pequenos traficantes'. E se o Estado ficar com comiseração com relação ao 'pequeno', ele estará dizendo: 'podem ter mil abelhas trabalhando, que eu farei vistas grossas, desde que eu consiga pegar alguém maior'. Isto vai acontecer cada vez mais o fracionamento do tráfico. Será um incentivo e será uma antipolítica de inteligência criminal. Nós não devemos esquecer que aquele que mata um, como que é aquele que mata, e pratica o crime de homicídio, estão ambos sujeitos às penalidades de prisão, por ter praticado o homicídio. Ontologicamente, quem trafica pouco, ou quem trafica muito, pratica o mesmo crime. Se esta pauta ou esta inteligência valer para esse tipo de crime, nós também vamos começar a dizer: 'olha, matou só um, não vale a pena de prisão; estuprou só uma, não valeria a pena de prisão'. E isto é, me parece, a anti-inteligência do Direito Penal, quando nós esquecemos, neste momento, do que seja a danosidade social deste crime de tráfico de drogas e do que ele pode acarretar recebendo um verdadeiro incentivo do Estado. É verdade, nenhum de nós fica feliz em assistir à punição de um traficante. Creio que não. O homem não deve se comprazer com a dor alheia - e sempre haverá dor àquele punido -, mas, como no velho poema de Augusto dos Anjos: 'a mesma mão que bate, é a mesma mão que acaricia'. Aqueles que não respeitam os regramentos de conveniência de uma sociedade politicamente organizada, à qual chamamos de Estado, nós precisamos chamar alguma força do Estado, para restabelecimento da ordem, sob pena de nós deixarmos a justiça por conta própria, a critério de cada qual. Há um pensamento, de cunho religioso, recitado desde sempre: 'quem tem piedade dos seus lobos, perderá suas ovelhas'. Quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, não pense somente no 'grande traficante'. Pode ser que apenas um, o pipoqueiro da escola, viciie o seu filho. E quando seu filho estiver viciado, e o futuro dele destruído, você entenderá que o 'pequeno' também pode ser um 'grande traficante', que levou o que de mais precioso você tem na vida, a sua descendência, a próxima geração" (fonte: youtu.be/1Pb_2RG_gcY).

Assim, verifica-se que todo "pequeno traficante" faz parte de uma imensa rede, chamada crime organizado, sendo eles a ponta danosa do iceberg, por serem quem leva a droga aos usuários, expondo a vida e saúde deles. Por tal razão, não há que se falar em tráfico privilegiado, por se dedicar o réu às atividades criminosas. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável

prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(...) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta

do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno WESLLEY MENEZES COSTALES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, e multa de 583 dias-multa, diária de R\$ 50,00, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

DECRETO a perda do dinheiro apreendido com o réu, dando-se a devida destinação.

Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual o réu poderá aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, mantidas as medidas cautelares fixadas pela decisão de fls. 79/81.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, expedindo-se mandado de prisão em regime fechado.

Condene o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, caso o réu seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA